Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Canoas

Rua Lenine Nequete, 60 - Bairro: Centro - CEP: 92310205 - Fone: (51) 3472-1184 - Email: frcanoas2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5034950-32.2021.8.21.0008/RS

AUTOR: VANDERLEI KNORST

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vanderlei Knorst ajuizou a presente **Ação de Obrigação de Fazer** contra **Unimed Porto Alegre - Cooperativa Médica Ltda**, partes já qualificadas. Alegou, em resumo, que é beneficiário do plano de saúde empresarial (ambulatorial + hospitalar com obstetrícia). Disse que é portador de neoplasia maligna do encéfalo (CID 10 C71), com a indicação de realização do seguinte plano de tratamento: Radioterapia seguida de Quimioterapia com o uso de TEMOZOLAMIDA de 380 mg por dia durante cinco dias. Ciclo a cada 28 dias, por 12 (doze) ciclos. Referiu que a radioterapia foi concluída em 03/11/2021, conforme nota de alta em anexo. Apontou que necessita, com urgência, iniciar a quimioterapia com o uso do medicamento TEMOZOLAMIDA 380 mg, por dia, conforme prescrição médica, o qual negado pela demandada, sob a justificativa de que a medicação em comento não atende a diretriz de utilização especificada no rol de coberturas obrigatórias dispostas nas Instruções Normativas 064 da RN 465/2021, da ANS, bem como de que o fármaco não possui registro na ANVISA. Salientou que a medicação, ao contrário do alegado pela ré, possui registro válido na ANVISA sob o nº 101710194. Asseverou que a medicação possui custo elevado e que não dispõe de recursos financeiros para arcar com tratamento. Requereu, em sede de tutela de urgência, a determinação de cobertura completa pelo plano de saúde demandado, do tratamento com o medicamento TEMOZOLAMIDA 380 mg por dia, durante 05 dias, ciclo a cada 28 dias, por 12 ciclos, conforme especificações constantes na receita médica em anexo. Postulou a procedência da ação, para tornar definitiva a tutela de urgência pleiteada. Pediu a assistência judiciária gratuita. Juntou documentos.

Deferida a assistência judiciária gratuita, foi concedida a tutela de urgência para determinar que a demandada fornecesse, no prazo de 5 dias, o tratamento prescrito, conforme receituário anexado aos autos - TEMOZOLIDA 380mg/dia, por 5 dias, ciclos a cada 28 dias, por 12 ciclos (documentos 8 e 9 do evento 1), pena de sequestro de valores (documento 1 do evento 3).

Citada, a requerida apresentou contestação (documento 1 do evento 16). Alegou, em suma, o recente julgado da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (REsp nº 1733013/PR), que adotou o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), previsto na Resolução Normativa 465/2021, não é meramente exemplificativo, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. Discorreu acerca da legitimidade da negativa de cobertura, tendo em vista a ausência de previsão à diretriz de utilização nº 64 da ANS. Asseverou que o medicamento em comento não é indicado para a enfermidade do autor na Diretriz nº 64 do Anexo II do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da RN nº 465/2021 da ANS. Apontou inexiste violação a qualquer regra contida no Código de Defesa do Consumidor, visto que não há abusividade, ausência de transparência e/ou informação ao consumidor na relação de consumo em tela. Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos.

Sobreveio réplica à contestação (documento 1 do evento 19).

Instadas acerca do interesse na produção de outras provas, as partes nada requereram.

Na sequência, os autos vieram-me conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.

PASSO A DECIDIR.

É caso de julgamento do processo no estado em que se encontra, na forma do art. 355, I, do CPC, pois a questão é essencialmente de direito e os documentos trazidos ao feito são suficientes para esclarecer os fatos.

Trata-se de ação ordinária, na qual pretende o autor o fornecimento do medicamento TEMOZOLAMIDA 380 mg/dia. Fundamenta sua pretensão, alegando que é portador de neoplasia maligna do encéfalo (CID 10 C71) e que necessita da medicação em comento, a qual possui custo elevado aludido, sendo que não dispõe de recursos para arcar com tratamento.

A requerida, por sua vez, sustenta que inexiste qualquer ilicitude em sua conduta. Afirma que o recente julgado da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (REsp nº 1733013/PR) adotou o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), previsto na Resolução Normativa 465/2021, não é meramente exemplificativo, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. refere que o medicamento em comento não é indicado para a enfermidade do autor na Diretriz nº 64 do Anexo II do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da RN nº 465/2021 da ANS.

Compulsando os autos, tenho que a procedência da ação é medida que se impõe.

Conforme é possível observar, resta incontroversa a relação contratual estabelecida entre as partes, não havendo dúvidas de que o requerente é beneficiário do plano de saúde fornecida pela demandada.

A matéria a ser enfrentada nestes autos cinge-se a apuração da existência de obrigatoriedade, da parte ré, em fornecer o medicamento postulado pelo autor.

Os serviços securitários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo, dispondo aquele diploma legal em seu art. 3º, § 2º, o seguinte:

Art. 3° - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° (...)

§ 2° - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Nos termos do art. 47 da referida lei, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Portanto, em caso de dúvida na aplicação dos dispostos contratuais plano ou seguro de saúde, a ação ou seu recurso, deverão ser julgados de forma a não prejudicar o consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica de consumo.

Como se sabe, o plano ou seguro de saúde não pode, segundo o previsto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem.

Desta forma, inobstante as operadoras de plano de saúde possam estabelecer quais as doenças cobertas, não podem limitar o tipo de tratamento a ser prescrito ao paciente, incumbência essa que cabe ao médico que assiste o paciente, ainda que não haja previsão em Rol da ANS, que é meramente exemplificativo, ou não atendida eventual diretriz de utilização.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1882735/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

Outrossim, embora não se desconheça o entendimento firmado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.733.013/PR), passando a interpretar o rol da ANS de coberturas como listagem taxativa, não se verifica uniformidade na jurisprudência da Corte Superior, tendo em vista que Terceira Turma da Corte Superior manteve o entendimento de que se trata de rol meramente exemplificativo.

Nesse ponto, cumpre transcrever parte do voto proferido pelo ilustre Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (no julgamento do AgInt no REsp 1.829.583/SP, cujo acórdão restou publicado em 26/06/2020), no sentido de que, mesmo em face do julgamento do REsp nº 1.733.013/PR pela e. Quarta Turma do Superior Tribunal, cuja ementa transcreve o douto Ministro, prevalece no âmbito da e. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS é meramente exemplificativo, *"in verbis"*:

"Registre-se, por fim, o advento, na egrégia QUARTA TURMA, de um precedente em sentido contrário ao deste voto.

Refiro-me ao precedente assim ementado:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em

saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais.8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020).

Esse precedente, contudo, não vem sendo acompanhado por esta TURMA, sendo oportuno, desde já, reafirmar a jurisprudência que prevalece neste colegiado" (Grifei).

Nesse sentido, é o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL (CPC/2015). CIVIL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM). DIVERGÊNCIA QUANTO À ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INGERÊNCIA NA RELAÇÃO CIRURGIÃO-PACIENTE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA TURMA. APLICABILIDADE ÀS OPERADORAS DE AUTOGESTÃO. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA. 1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de cirurgia para tratamento de degeneração da articulação temporomandibular (ATM), pelo método proposto pelo cirurgião assistente, em paciente que já se submeteu a cirurgia anteriormente, por outro método, sem obter êxito definitivo. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato. 3. Caso concreto em que a necessidade de se adotar procedimento não previsto no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato de o paciente já ter se submetido a tratamento por outro método e não ter alcançado êxito. 4. Aplicação do entendimento descrito no item 2, supra, às entidades de autogestão, uma vez que estas, embora não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, não escapam ao dever de atender à função social do contrato. 5. Existência de precedente recente da QUARTA TURMA no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS. 6. Reafirmação da jurisprudência desta TURMA no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020).

Diante disso, evidente que se mostra abusiva e ilegal a recusa da requerida em custear o tratamento prescrito pelo médico que assiste o autor, sob a alegação de que não foram atendidos os requisitos constantes nas diretrizes de utilização da ANS.

A respeito, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO INTRA-OCULAR COM ANTIANGIOGÊNICO. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. COBERTURA DEVIDA. 1. O contrato em análise foi avençado entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento das despesas médicas e hospitalares para a hipótese de ocorrer a condição suspensiva prevista naquele pacto, consubstanciada no evento danoso à saúde. Outro elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na forma do art. 422 do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza das informações prestadas pelas partes. 2. Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. 3. Com efeito, são aplicáveis ao caso em exame as exigências mínimas previstas no plano-referência de que trata os artigos 10 e 12 da legislação dos planos de saúde. ***4. Ademais, cumpre salientar que o rol de procedimentos publicado pela ANS constitui apenas uma referência básica de coberturas obrigatórias nos plano privados de assistência a saúde. No que diz respeito ao não preenchimento das condições elencadas nas diretrizes de utilização do procedimento, impende destacar que o médico assistente da parte autora destacou a necessidade do tratamento postulado. 5. não cabe à demandada determinar o tipo de tratamento que será realizado pela parte autora, uma vez que esta decisão cabe ao médico que a acompanha, o qual possui a capacidade de avaliar os riscos e benefícios para o caso específico, indicando o procedimento adequado para as patologias apresentadas. 6. A omissão no contrato quanto à exclusão de cobertura deve ser interpretada de forma favorável ao consumidor, uma vez que a negativa do apelante não se pautou em determinação contratual. Inteligência do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.*** *7. Os honorários advocatícios deverão ser majorados quando a parte recorrente não lograr êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel CPC. Negado provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70077431153, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 30/05/2018. Grifei).*

Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Denervação Percutânea da Faceta Articular por seguimento. ***- Negativa de cobertura sob a alegação de que o tratamento indicado não preenche as diretrizes do rol da ANS Descabimento. Dever de custear o tratamento. Existência de prescrição médica. Intervenção que se mostra necessária ao completo restabelecimento da saúde do autor. Aplicação do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.*** *Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas. - Danos morais não configurados. Recusa de cobertura que, em regra, não gera o dever de indenizar. Ausência de indícios de que a conduta da ré tenha agravado o quadro clínico ou colocado em risco a saúde do autor. Sentença mantida. À unanimidade negaram provimento aos apelos. (Apelação Cível Nº 70075867622, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 26/04/2018. Grifei).*

De acordo com os documentos que instruem a exordial, verifica-se que o autor foi diagnosticado com neoplasia maligna do encéfalo (CID 10 C71), sendo que, após a realização de procedimento cirúrgico, foi encaminhado para tratamento com médico oncologista, o qual lhe prescreveu tratamento quimioterápico com o uso do medicamento TEMOZOLAMIDA 380 mg/dia, por 5 dias, ciclos a cada 28 dias, por 12 ciclos, conforme receituário anexado aos autos (documentos 8 e 9 do evento 1).

Deste modo, tenho que os documentos em comento são suficientes para demonstrar a necessidade da realização do tratamento prescrito ao demandante.

Assim, repito, é descabida a negativa de cobertura, por parte da demandada, sob o fundamento de que não preenchidas as condições elencadas nas diretrizes de utilização do procedimento, pois o médico assistente do autor prescreveu o medicamento postulado.

Ademais, não cabe à requerida determinar o tipo de tratamento que será realizado pela parte autora, uma vez que esta decisão cabe ao médico que a acompanha, que possui a capacidade de avaliar os riscos e benefícios para o caso específico, indicando o procedimento que entende adequado para a patologia apresentada.

Destarte, tenho que a procedência da ação é medida que se impõe, cumprindo, pois, confirmar a tutela de urgência concedida no evento 3.

Isto posto**, JULGO PROCEDENTE** a presente **Ação de Obrigação de Fazer** ajuizada por **Vanderlei Knorst** contra **Unimed Porto Alegre - Cooperativa Médica Ltda**, partes já qualificadas, para CONDENAR a demandada a fornecer para o autor o medicamento TEMOZOLAMIDA 380 mg/dia, por 5 dias, ciclos a cada 28 dias, por 12 ciclos, conforme receituário anexado aos autos (documentos 8 e 9 do evento 1), ou efetue o depósito judicial em valor suficiente para que seja custeado o tratamento, cumprindo, pois, confirmar a medida de tutela de urgência concedida nestes autos.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios dos procuradores da parte adversa, os quais fixo em R$ 1.300,00, corrigidos, pelo IGP-M, desde a data da publicação da sentença, até o efetivo pagamento, forte no art. 85, § 8º, do CPC.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA ROSA MOROZINI, Juíza de Direito**, em 18/4/2022, às 15:38:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10017843590v2** e o código CRC **8a74273b**.